

제61회 변리사 시험 상표법 해설

By. 한빛 상표법 강사진

안녕하세요.

한빛 상표법 강사진입니다.

제61회 변리사 2차 시험이 끝났습니다.

덥고 습한 날씨에 시험보시느라 모두 고생많이하셨습니다.

다들 후회없이 치열하게 시험 보셨기를 기원합니다.

올해 상표법 문제는 난이도는 무난한 편이었습니다.

그러나, 무난한 논점에서 차별성을 만들어내는 답안을 구성하는 점, 갑자기 20페이지로 답안지가 늘어난 점, 시험장에서의 중압감 그리고 무엇보다 1교시에 한번도 경험하지 못한 특허법 문제 유형을 접하신 상태에서 시험을 치르신 것을 감안하면 마냥 쉽지만은 않았을 것입니다. 4문제 모두 판례형 문제에 사례 문제를 소설문으로 가미한 형식이었으므로 판례를 풍부하게 쓰신 분들은 고득점을 기대하실 수 있는 해라고 생각합니다.

변리사 2차 시험은 4가지 종목을 모두 잘해야하는 종합 스포츠, 종합 예술이라고 생각합니다. 모든 과목에서 후회 없는 준비기간과 후회 없는 시험을 치르셨기를 믿어 의심치 않으면서 여러분의 합격을 기원하겠습니다.

2024. 07. 27. 15:30.

김세원, 김주안, 천훈기, 김수영, 정혜진 드림.

*본 해설 자료는 강사진이 작성한 견해에 불과하므로 이의신청의 근거가 될 수 없습니다.

甲은 상품류 구분 제44류 ‘동물을 위한 위생 및 미용서비스업’에 대하여 한글로 된 상표 ‘애니진’을 2021. 10. 15.(금) 상표등록출원하여 2022. 10. 14.(금) 상표등록을 받았다. 다만, 甲은 상표권 설정등록 이후에 이 상표를 지정서비스업에 사용하지 않고 있다. 乙은 반려동물 애호가로서 ‘동물을 위한 위생 및 미용서비스업’을 운영하기 위하여 2022. 5. 10.(화) ‘애니진’이라는 상호로 주식회사를 설립하여 법원에 설립등기를 마쳤다. 乙은 2022. 11.부터 ‘동물을 위한 위생 및 미용서비스업’에 대하여 표장 “



(이하 ‘표장 1’이라 함)”을 사용하고 있다.

그 후 乙은 2023. 5.부터 ‘동물을 위한 위생 및 미용서비스업’에 대하여 표장 “



(이하 ‘표장 2’라 함)”을 인터넷 웹사이트에서 사용하고 있다. 다음

물음에 답하시오.

(1) 乙의 ‘표장 1’과 ‘표장 2’가 甲의 상표권을 침해하였는지 여부에 대하여 판단하시오. (14점)

(2) 甲은 乙에 대하여 상표권 침해 주장을 하면서 상표법 제 109조(손해배상의 청구) 및 제111조(법정손해배상의 청구)에 의한 손해배상을 청구하였다. 甲의 손해배상이 인정될 수 있는지 여부에 대하여 판단하시오. (8점)

(3) 甲의 상표권 침해 주장에 대하여 乙은 甲의 상표권 행사가 권리남용이라고 판단하고 있다. 등록상표에 무효사유와 취소사유가 있는 경우에 권리남용의 적용 여부 및 상표권자의 권리행사가 권리남용이 되는 경우에 대하여 대법원의 판례를 중심으로 설명하시오. (8점)

<Comment.>

과거 기출되었던 크라운진 判例가 전면적으로 재출제 된 것으로 보입니다. 크라운진 판례의 법리는 이미 다양한 기본서에서 중요하게 다루고 있고, 무엇보다 손해배상 쟁점은 GS들에서도 중요하게 다룬 논점이므로 아시는 법리로 풍부하게 써주시는게 고득점 포인트라고 생각합니다.

[문제-1] “애니진 문제” (상표법은 이하 ‘法’ 이라 함)

I. 설문 (1)의 해결

1. 침해의 요건 및 문제의 소재

2. 乙의 상표 사용이 상표적 사용인지 여부

(1) 상표적 사용의 개념

(2) 소결

1) 표장 1 - 상표적 사용으로 인정됨

2) 표장 2 - 웹사이트에서 사용되는 것도 상표적 사용으로 인정됨(개정법 언급 가능)

3. 사용상표 1 및 2가 등록상표와 유사한지 여부

(1) 判例 - 상표 유사판단

1) 원칙

2) 결합상표의 경우

(2) 소결

1) 표장 1 - 상표유사

2) 표장 2 - MK-Gene으로 인하여 출처혼동의 염려가 없으므로 상표 비유사

4. 乙의 法90조 1항 1호의 효력제한사유 주장가부

(1) 法90조 1항 1호의 의의 및 취지

(2) 判例 - 결합상표의 일부에 효력제한사유 주장 가부

1) 결합상표 일부에 효력제한사유가 있는 경우

[대법원 判例] “상표권의 권리범위확인심판 청구에서 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 확인 대상표장이 둘 이상의 문자·도형 등의 조합으로 이루어진 결합표장인 경우, 그 전체뿐만 아니라 그 중 분리인식될 수 있는 일부만이 法90조 1항 각 호에 해당하더라도 거기에 상표권의 효력은 미치지 아니하는 것이다.” 라고 한다.

2) 결합상표 일부에 효력제한사유가 있는 경우 상표의 권리범위 판단방법

[대법원 判例] “상표권의 효력이 미치지 아니하는 부분이 확인대상표장에 포함되어 있다면 확인 대상표장 중 그 부분을 제외한 나머지 부분에 의하여 등록상표와 사이에 상품출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있는지를 기준으로 하여 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부를 판단해야 한다.” 고 한다.

(3) 소결

1) 표장 1 - 상호를 변형한 것으로 상거래관행에 따른 사용이 아님/주장 불가

2) 표장 2 - (주) 애니진에 대하여 주장가능하므로, MK-Gene이 등록상표의 권리범위에 속하는지 판단해야 함.

5. 甲의 권리남용 여부

甲의 등록상표에 무효사유가 명백한 것은 아니므로 권리남용 주장 불가

6. 결론

1) 표장 1의 사용은 침해인정

2) 표장 2는 침해부정

II. 설문(2)의 해결

1. 문제의 소재

2. 法109조에 따른 손해배상청구 인정가부

(1) 의의, 취지 및 요건 - 고/위/손/인

(2) 乙의 고의/과실 인정 여부

1) 判例 - 과실은 추정

2) 소결 - 乙의 과실이 추정됨

(3) 乙의 손해 불발생항변 가부

1) 判例

① 원칙

[대법원 判例] “상표권은 특허권 등과 달리 등록되어 있는 상표를 타인이 사용하였다는 것만으로 당연히 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액이 손해로 인정되는 것은 아니고, 상표권자가 상표를 영업 등에 실제 사용하고 있었음에도 상표권 침해행위가 있었다는 등 구체적 피해 발생이 전제되어야 인정될 수 있다.” 고 한다.

② 손해 불발생 항변 인정 가부

[대법원 判例] “상표권자가 상표를 등록만 해 두고 실제 사용하지는 않았다는 등 손해 발생을 부정할 수 있는 사정을 침해자가 증명한 경우에는 손해배상책임을 인정할 수 없다.” 고 한다.

2) 소결

甲은 등록상표를 사용하고 있지 않으므로 乙이 손해 불발생항변을 하는 경우 法109조에 따른 손해배상청구 불가

3. 法111조에 의한 손해배상청구 인정가부

(1) 의의 및 취지

(2) 判例 - 법정손해배상청구에 대한 판단방법

1) 판단원칙

[대법원 判例] “法111조는 위조상표의 사용 등으로 인한 상표권 침해행위가 있을 경우에 손해액수의 증명이 곤란하더라도 일정한 한도의 법정금액을 배상받을 수 있도록 함으로써 피해자가 쉽게 권리구제를 받을 수 있도록 하는 예외적 규정이므로, 그 적용요건은 법문에 규정된 대로 엄격하게 해석하여야 한다.” 고 한다.

2) 판단방법

[대법원 判例] “ i) 상표권자가 法111조에 따른 손해배상을 청구하려면, 상표권 침해 당시 등록상표를 상표권자가 실제 사용하고 있었어야 하고, ii) 침해자가 사용한 상표가 상표권자의 등록상표와 같거나 동일성이 있어야 하며, iii) 동일성 요건을 갖추지 못한 경우에는 통상의 방법으로 손해를 증명하여 배상을 청구하여야지 법정손해배상을 청구할 수는 없다.” 고 한다.

(3) 소결

등록상표와 표장 1 및 2는 동일성 인정되지 않고, 甲도 등록상표 사용하지 않으므로 인정불가

Ⅲ. 설문(3)의 해결

1. 문제의 소재

2. 권리남용의 개념

3. 등록상표에 무효사유가 있는 경우 권리남용 인정가부

(1) 判例의 태도

1) 등록상표에 무효사유가 명백한 경우

[전원합의제 判例] “등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 상표등록이 무효 심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 한다.” 고 한다.

2) 법원이 상표등록의 무효여부를 심리, 판단할 수 있는지 여부

[전원합의제 判例] “상표권침해소송을 담당하는 법원으로서도 상표권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 상표등록의 무효 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다.” 고 한다.

(2) 소결

甲의 등록상표에 특별히 무효사유가 존재하지는 않는 것으로 판단되므로 乙의 판단은 부당

4. 등록상표에 취소사유가 있는 경우 권리남용 인정가부

(1) 判例의 태도

[대법원 判例] “적법하게 출원·등록된 상표인 이상 비록 등록취소사유가 있다 하더라도 그 등록취소심결 등에 의하여 취소가 확정될 때까지는 여전히 유효한 권리로서 보호받을 수 있으므로, 그 상표권에 기한 금지청구가 권리남용 또는 신의칙 위반에 해당된다고 볼 수 없다.” 고 한다.

(2) 소결

취소사유가 명백하더라도 권리남용은 인정 불가하므로 乙의 판단은 부당

5. 상표권자의 권리행사가 권리남용으로 인정되는 유형

(1) 判例 - 적극적 권리남용

(2) 判例 - 역혼동에 의한 권리남용 인정가부 - 인정하지 않음

6. 결론

甲은 지정상품 ‘화장품, 바디로션, 스킨로션’에 대하여 상표 X를 부착하여 2018. 12. 4. (화) 상표등록출원을 하여 2019. 10. 17.(목) 상표등록을 받았다. 甲은 2020. 1. 10.(금) 乙과 독점적 통상사용권 설정계약을 체결하였다. 乙은 2020. 3. 11.(수)부터 거래처인 화장품 스토어에 화장품을 공급하는 과정에서 지정상품과 그 지정상품의 포장에 등록상표 X를 사용하지 않고, 물품공급계약서, 견적서와 거래명세서에 거래통념상 등록상표 X와 동일하게 볼 수 있는 형태의 실사용표장 X'를 표시하여 거래 상대방에게 교부하고 있다.

한편, 丙은 2023. 4. 14.(금) 상표 X에 대하여 특허심판원에 상표법 제119조(상표등록의 취소심판) 제1항 제3호에 의한 불사용 상표등록취소심판을 청구하였다. 그 후 丙은 甲과 乙의 허락 없이 2023. 11. 10.(금)부터 지정상품 ‘핸드로션, 화장품 마스크팩’에 대하여 상표 X를 부착하여 판매하고 있다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 특허심판원이 丙의 불사용 상표등록취소심판에 대해 인용심결을 한 경우에, 이에 대하여 甲이 취할 수 있는 상표법상의 대응조치 및 그 결과에 대하여 논하시오. (8점)

(2) 丙이 상표 X를 사용하는 행위에 대하여 乙이 취할 수 있는 상표법상의 조치에 대하여 설명하시오. (5점)

(3) 甲이 질환으로 사망한 후 그의 유족 丁이 상표권을 상속받은 경우에, 丁과 丙 및 丁과 乙의 법적 관계에 대하여 설명하시오. (7점)

<Comment.>

최근 중요 판례로 찍힌 컨투어 코일 판례 기반 문제로 보입니다. 설문 (1)은 거래서류에 상표를 표시한 것, 동일성 있는 상표에 대한 법리를 풍부히 기재하시면 좋은 점수가 예상됩니다. 설문(2) 및 (3)은 쌍돌성 문제인데, 다양한 GS 수업에서 연습하셨듯이 물어보는대로 문제를 풀어나가시면 되는 문제입니다. 논리적인 답안을 전개하셨다면 당락에 영향을 미칠 수 있는 점수차는 없을 것으로 예상됩니다.

[문제-2] “불사용 취소심판 문제” (상표법은 이하 ‘法’ 이라 함)

I. 설문(1)의 해결

1. 문제의 소재

2. 甲이 취할 수 있는 조치 - 심결취소소송

(1) 심결취소소송의 의의 및 취지 - 法162조

(2) 소결

甲은 인용심결에 대하여 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있고, 무제한설의 원칙상 法119조 1항 3호에 대한 심판원 판단의 위법성을 판단하게되는바, 이하 法119조 1항 3호의 취소사유 존부를 검토함.

3. 法119조 1항 3호의 의의, 취지 및 요건

4. 乙의 등록상표 사용여부

(1) 상표적 사용의 개념(형식/실질)

(2) 거래명세서에 교부한 것이 광고행위인지 여부

1) 判例

① 거래서류의 종류

[대법원 判例] “ ‘거래서류’ 는 거래에 제공되는 서류로서 주문서, 납품서, 송장, 출하안내서, 물품영수증, 카탈로그 등이 이에 포함된다.” 고 한다.

② 거래서류의 판단

[대법원 判例] “상품의 판매업자가 지정상품과의 구체적인 관계에서 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 상품에 관한 거래서류에 상표를 표시하고 상품거래과정에서 일반 공중에 속하는 거래상대방에게 이를 교부하였다면, 거래서류를 일반 공중이 인식할 수 있는 상태에 두었다고 볼 수 있으므로, 특별한 사정이 없는 한 (다)목이 규정하고 있는 상표의 사용에 해당한다.” 고 한다.

2) 소결

乙이 등록상표를 계약서, 견적서 및 거래명세서에 사용한 것은 法2조 1항 11호 다목에서 규정하는 거래서류에 등록상표를 표시한 것이므로 형식적 사용인정.

(3) 실사용표장 X' 의 사용에 대한 판단

(1) 判例 - 法119조 1항 3호에서의 상표의 사용

[전원합의제 判例] “불사용으로 인한 상표등록취소 제도의 취지에 비추어 볼 때, 여기서 ‘등록상표를 사용’ 한다고 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 아니하나, ‘동일한 상표’ 에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함된다고 할 것이다.” 라고 판시하였다.

(2) 소결

거래통념상 등록상표 X와 동일하게 볼 수 있는 상표 X' 를 사용한 것이므로 등록상표의 사용으로 인정가능.

5. 설문의 해결

乙의 사용으로 法119조 1항 3호의 취소사유를 인정한 심판원 판단은 잘못됨. 따라서, 특허법원은 甲이 제기한 심결취소소송에 대하여 인용판결해야함.

II. 설문(2)의 해결

1. 乙이 침해금지청구권 행사가부

乙은 통상사용권자에 불과하므로 직접 침해금지청구권을 행사할 수 없음.

2. 乙이 甲의 침해금지청구권을 대위행사할 수 있는지 여부

상표법상 判例는 없으나, 저작권법상 인정된 사례가 존재하므로 침해금지청구권을 대위청구 하는 것은 고려가능.

3. 乙의 손해배상청구 가부

(1) 判例 - 특허 판례에서 인정한 바 있음.

(2) 소결 - 민법상 불법행위책임을 물을 수 있음.

III. 설문(3)의 해결

1. 상표권 이전의 효과 발생여부

상속은 일반승계이므로 등록할 필요 없이 상표권을 상속한 것으로 인정되고(法96조 1항 1호), 3년 내에만 이전등록하면 됨(法106조 1항). 따라서, 丁은 상표권자의 지위를 그대로 승계함.

2. 丁과 丙의 관계

(1) 丙의 상표권 침해여부

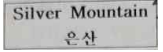
丁은 정당한 상표권 상속인이므로 丁의 상표권을 丙은 침해하는 것임.

(2) 丁이 할 수 있는 조치

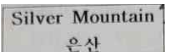
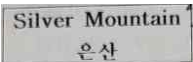
- 1) 민사상 조치 - 침손심부
- 2) 형사상 조치 - 침양

3. 丁과 乙의 관계

일반승계로 모든 내용이 자동승계 되므로 여전히 乙은 丁에 대하여 독점적 통상사용권자임.

甲은 2020년부터 ‘시계’를 지정상품으로 하여 ‘은산’을 상표등록하고 시계 제조·판매업을 영위하여 왔다. 乙은 2000년부터 ‘Silver Mountain’이라는 상표를 붙여 액세서리를 제조·판매하였는데, 그 품질과 디자인의 우수성으로 인해 액세서리 시장에서 일반 수요자들과 거래종사자들 사이에서 ‘Silver Mountain’은 乙의 액세서리를 표시하는 상표로서 유명해졌다. 그러자 甲은 자신이 제조·판매하는 시계 및 그 포장에 ‘,’이라는 상표를 붙여 판매하였다. 乙은 甲의 등록상표 ‘은산’에 대하여 상표법 제119조(상표등록의 취소심판) 제1항 제1호를 근거로 등록취소심판을 청구하였다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

(1) 甲의 등록상표가 상표법 제119조 제1항 제1호의 요건(‘甲의 등록상표와 실사용상표의 유사성’과 ‘乙의 업무와 관련된 상품과 혼동을 일으키는지’)을 모두 충족하였는지 논하시오. (12점)

(2) 한편, 乙이 위 등록취소심판을 청구하기 1년 전에 甲과 乙은 “甲은 ‘,’을 ‘시계제품에 한정’하여 상표로 사용할 수 있다.”고 합의하였다. 甲은 “甲이 ‘,’을 시계제품에 상표로 사용하는 것에 대하여 乙이 이미 합의하였으므로, 甲의 등록상표는 乙의 취소심판청구 대상이 될 수 없다.”고 주장하였다. 甲의 주장이 타당한지 논하시오. (8점)

(3) 만약 甲과 乙이 “乙은 甲의 등록상표 ‘은산’에 대한 취소심판청구를 취하하고, 대신 乙이 ‘은산’을 지정상품을 시계제품으로 한정하여 상표등록하는 것에 甲이 동의”하는 내용에 합의하였다면, 乙이 시계를 지정상품으로 ‘은산’을 상표등록할 수 있는지 논하시오. (10점)

<Comment.>

최근 중요 판례로 찍힌 금강 판례 및 소문난 삼부자의 출처혼동 실시내용을 기반으로 출제된 문제로 보입니다. 설문 (1)은 法119조 1항 1호의 ‘유사상표 요건’ 및 ‘출처혼동요건’의 법리를 풍부히 기재하 시면 좋은 점수가 예상됩니다. 설문(2)는 금강 판례에서 문제가된 심판청구권 남용에 대한 논점으로 보입니다. 法119조 1항 1호의 취지를 기반으로 문제를 풀어나가시면 좋은 점수를 받으실 수 있을 것으로 예상됩니다. 설문(3)은 최근 도입된 공존동의제도에 대한 문제로 보입니다. 배경이 커보이나 개정의 취지와 공존동의에 대한 내용(시기/방식)등을 풍부히 쓰시면 좋은 점수를 받으실 것으로 보입니다.

[문제-3] “은산 문제” (상표법은 이하 ‘法’ 이라 함)

I. 설문(1)의 해결

1. 문제의 소재

2. 法119조 1항 1호의 의의, 취지 및 요건

3. 甲의 法119조 1항 1호의 ‘유사상표’ 사용 여부

(1) 判例 - 유사상표 사용의 의미

[대법원 判例] “실사용상표가 등록상표를 대상상표와 동일 또는 유사하게 보이도록 변형한 것이어서 그 사용으로 인하여 대상상표와의 관계에서 등록상표를 그대로 사용한 경우보다 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 된 경우, 法119조 1항 1호에서 정한 부정사용을 이유로 한 상표 등록취소심판에서는 실사용상표의 사용을 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 볼 수 있다.” 고 한다.

(2) 소결

甲은 한글로 된 상표만을 등록받고 지정상품 ‘시계’와 경제적 관련성이 있는 액세서리에 대하여 유명해진 乙의 실사용상표 ‘Silver Mountain’을 결합하여 사용하므로 등록상표만을 사용한 경우보다 수요자 간 출처의 혼동 염려가 더 커진 경우임. 따라서, 甲의 사용은 法119조 1항 1호에서의 유사상표의 사용임.

4. 法119조 1항 1호의 ‘출처혼동’ 요건 만족 여부

(1) 乙의 실사용상표의 대상상표 적격성

1) 判例

① 대상상표의 인식도

[대법원 判例] “대상상표는 적어도 국내에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있을 것을 요한다.” 고 하면서, “대상상표가 주지·저명한 것임을 요하는 것은 아니다.” 라고 한다.

② 대상상표가 등록상표의 권리범위에 속하는 경우

[대법원 判例] “타인의 상표가 당해 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니라고 하더라도 그 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있다.” 고 한다.

2) 소결

乙의 상표는 乙의 액세서리를 표시하는 상표로 유명해진 것이고, 甲의 등록상표와 관념이 유사하여 설령 甲의 등록상표의 권리범위에 속할 여지가 있더라도 判例에 따라 대상상표의 적격성 인정됨.

(2) 출처혼동의 염려에 대한 판단

1) 判例

[대법원 判例] “각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰하되, 실사용상표가 등록상표로부터 변형된 정도 및 대상상표와 유사한 정도, 실사용상표와 대상상표가 상품에 사용되는 구체적인 형태, 사용상품 간의 관련성, 각 상표의 사용 기간과 실적, 일반 수요자에게 알려진 정도 등에 비추어, 당해 상표의 사용으로 대상상표의 상품과 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가를 중점적으로 살펴야 한다.” 고 한다.

2) 소결

甲의 실사용상표는 乙의 대상상표와 호칭이 동일하고, 관념도 동일하며, 사용상품 또한 乙의 액세서리와 유사하거나 경제적 관련성이 있는 것이므로 출처 혼동의 염려가 객관적으로 존재함.

5. 설문의 해결

甲의 등록상표의 사용은 부정사용으로 法119조 1항 1호의 요건을 만족함.

II. 설문(2)의 해결

1. 문제의 소재

2. 乙의 심판청구가 권리남용인지 여부

(1) 判例의 태도

1) 法119조 1항 1호의 취지

[대법원 判例] “상표제도의 본래의 목적에 반하여 자신의 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품 거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하려는 행위를 방지하여 거래자와 수요자의 이익보호는 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데 그 취지가 있다.” 고 한다.

2) 분쟁발생방지 합의가 있는 경우

[대법원 判例] ‘法119조 1항 1호가 상품 거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하려는 행위를 방지하여 거래자와 수요자의 이익보호는 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데 그 취지가 있는 공익적 규정인 점까지 감안하면 ‘분쟁발생방지 합의’가 존재한다는 사정만으로는 심판청구가 권리남용에 해당한다고 할 수는 없다.’ 고 설시하였다.

(2) 소결

法119조 1항 1호의 공익적 성격을 고려하면 乙의 심판청구는 권리남용이 아니므로 적법하다.

3. 설문의 해결 - 甲 주장의 타당성

乙과 甲의 상표 사용합의가 있다고 하더라도 法119조 1항 1호의 공익적 취지상 乙의 심판청구는 심판청구권을 남용하는 것이 아님. 따라서, 甲의 주장은 부당함.

III. 설문(3)의 해결

1. 문제의 소재

2. 문제되는 등록요건

(1) 法34조 1항 7호의 의의 및 취지

(2) 소결

3. 2024년 5월 1일 시행 공존동의제도 활용가부

(1) 의의 및 취지 - 法34조 1항 7호 단서

(2) 개정법 도입의 취지 및 시행일

상표의 안정적 사용 도모, 2024년 5월 1일 이후 등록여부결정시 도래하는 경우 적용 가능

(2) 내용 - 공존 동의 입증 방법

출원시 출원서에 공존동의서 첨부 가능하고, 공존동의대상 상표 및 상품을 명시해야함

(3) 소결

동일상표를 동일상품에 대하여 등록받는 것에 대한 동의를 한것이므로 공존동의 활용 불가

4. 설문의 해결

乙은 공존동의제도를 활용할 수 없는 이상 ‘은산’을 상표로 등록받을 수 없음.

甲은 ‘헬스클럽경영업 등’을 지정서비스업으로 하여 ‘SPRING FITNESS’를 상표등록하고 자신이 운영하는 헬스클럽의 상표로 사용하였다. 乙은 甲이 위 상표를 등록출원하기 전에 한글상호인 ‘스프링 피트니스’로 사업자등록하고, 영문표기로 자신의 헬스클럽을 영업시설과 인터넷에서 홍보하였다. 乙이 홍보에 사용한 영문표기는 두 개였는데, ‘S(P)RING’ (이하 ‘사용상표1’이라 한다.)과 ‘SPRING FITNESS’ (이하 ‘사용상표2’라 한다.)였다. 甲은 乙에 대하여 등록상표권 침해소송을 제기하였다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 乙은 甲의 등록상표 ‘SPRING FITNESS’ 중 ‘FITNESS’ 부분은 “지정서비스업인 헬스클럽경영업이 직감” 되므로 식별력이 없고, ‘SPRING’ 부분은 “헬스클럽을 다닌 결과 몸이 스프링과 같이 탄력있게 될 수 있다는 뜻” 이므로 식별력이 없다고 주장하였다. 乙의 주장이 타당한지 논하시오. (12점)

(2) 법원은 甲의 등록상표를 구성하는 ‘FITNESS’ 부분과 ‘SPRING’ 부분의 각각의 식별력과는 별개로 ‘SPRING FITNESS’는 전체를 하나로 보아서 식별력이 있고, 甲의 등록상표와 乙의 사용상표들과의 유사성이 인정된다고 판단하였다. 이에 대하여 乙은 사용상표1과 사용상표2가 상표법 제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위) 제1항 제1호에 해당한다고 주장하였다. 乙의 주장이 타당한지 논하시오. (8점)

<Comment.>

최근 중요 판례로 찍힌 번피트니스 판례 기반으로 출제된 문제로 보입니다. 설문 (1)은 침해소송에서의 주장이므로 본질적 식별력보다 ‘상대적인 식별력’을 중심으로 내용을 전개해 나가시면 좋은 점수를 받으실 것으로 예상됩니다. 설문(2)는 法90조 1항 1호에 대한 문제입니다. 번피트니스 판례의 대법원에서 설시해줬으면 정말 좋았을 텐데 한글상호를 영문으로 변환한 것에 대하여 그냥 상거래 관행에 따른 사용을 인정해서 중요할 수 있는 부분이라고 많은 수업에서 설명되었을 것입니다. 설령 해당 부분 준비가 안되었어도 논점 자체를 주고 있으므로 아시는 내용을 풍부히 쓰시면 좋은 점수를 받으실 수 있을 것으로 예상됩니다.

[문제-4] “스프링 피트니스 문제” (상표법은 이하 ‘法’ 이라 함)

I. 설문(1)의 해결

1. 문제의 소재

2. 결합상표 유사판단과 요부관찰의 법리

(1) 전체관찰의 원칙

대법원 判例는 상표의 유사판단에 대하여 “두 개의 상표를 외관·호칭·관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판단한다.” 고 일관된 입장을 제시한다.

(2) 전체관찰을 보완하기 위한 요부관찰 및 분리관찰

1) 요부관찰의 법리

① 요부관찰의 개념

대법원 判例는 “상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다.” 고 실시하여 요부관찰의 개념을 도입하고 있다.

② 요부의 결정기준

대법원 判例는 i) “식별력이 미약한 부분은 요부가 될 수 없다.” 고 하면서, ii) 상표의 구성 부분이 요부인지는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.” 고 한다.

3. 설문의 해결 - 乙주장의 타당성

(1) SPRING 부분의 상대적인 식별력 판단

FITNESS는 헬스클럽경영업에 대한 성질을 직감하게 하므로 식별력이 없으나, SPRING은 헬스클럽경영업을 암시할 뿐이므로 상대적인 식별력이 높음.

(2) 결론

i) FITNESS 부분은 헬스클럽경영업이 직감되므로 FITNESS 부분의 식별력이 없다는 주장은 타당하나, ii) SPRING 부분은 헬스클럽경영업을 암시할 뿐이고 직감하게 하는 것은 아니므로 FITNESS 부분에 비하여 상대적인 식별력이 높음. 따라서, SPRING이 식별력이 없다는 주장은 부당함. 결론적으로 乙의 주장은 부당하고 SPRING 부분은 상표 유사판단시 요부로 작용 가능함.

II. 설문(2)의 해결

1. 문제의 소재

2. 法90조 1항 1호의 의의 및 취지

3. 2016년 9월 1일 시행 개정법의 태도

4. 判例 - 상거래 관행에 따른 사용

(1) 구법상 判例

구법상 判例는 ‘상호를 상거래 관행에 따라 사용한다.’ 는 것은 표장 자체가 특별한 식별력을 갖도록 표시되었는지, 사용된 표장의 위치, 배열, 크기, 다른 문구와의 연결관계, 도형과 결합되어 사용되

있는지 여부 등 실제 사용태양을 종합하여 거래통념상 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하는지 여부를 판단하여야 한다.” 고 판시하였다.

(2) 최근 判例

최근 대법원 判例는 ‘번피트니스’ 라는 상호를 ‘BURN FITNESS’ 로 표기한 것을 상거래 관행에 따른 사용으로 인정한 바 있음.

(3) 검토

2016년 9월 1일 시행 전면 개정법은 종래 判例의 해석을 반영하여 ‘보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’의 요건을 ‘상거래 관행에 따른 사용’으로 개정하였는바, 개정법에도 위 判例의 적용이 가능할 것이다.

5. 설문의 해결

(1) 사용상표 1에 대한 주장

SPRING 중 ‘S, P, R’를 원문자로 구성하여 일부 도안화 한 것으로 판단되는바 상거래관행에 따른 사용으로 볼 수 없음. 따라서 사용상표 1에 대하여 乙의 주장은 부당함.

(2) 사용상표 2에 대한 주장

개정법 및 최근 판례의 경향에 따르면 한글 상호를 단순히 동일한 음역의 영어 문자로 구성한 정도는 상거래 관행에 따른 사용으로 볼 수 있음.